



**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC**

PRUEBA – DEFINICIÓN/ REQUISITOS – Conducencia, Pertinencia, Utilidad.

Doctrinariamente se define como objeto de la prueba, todo hecho que precisa demostración en el expediente, por constituir presupuesto de la decisión. Entonces la prueba debe estar enfocada o encaminada a todos aquellos aspectos de discusión que puedan servir de base para la definición de la situación jurídica del procesado. Con base en lo anterior, el artículo 132 de la Ley 734 de 2002 establece los requisitos básicos para la admisión de las pruebas, relacionados con su conducencia, pertinencia y utilidad.

La conducencia de la prueba tiene que ver con la capacidad de esta para demostrar un determinado acontecimiento; la pertinencia como la coherencia entre la situación investigada y la prueba a realizar, mientras la utilidad refiere a la trascendencia o riqueza probatoria que aporta la probanza a la investigación. Deben así inadmitirse las pruebas que resulten inconducentes, igualmente, las ilegales o ineficaces, las que versen sobre hechos impertinentes y las manifiestamente superfluas¹.

Sobre este tópico la Jurisprudencia Constitucional ha precisado que el principio de pertinencia y conducencia e idoneidad de la prueba, constituyen una limitante a la libertad de la presentación de la prueba y están relacionados con los denominados requisitos intrínsecos del acto probatorio, pues de no ser así, al proceso concurrirían toda suerte de pruebas que al final no sería mucho lo que finalmente aporten al esclarecimiento de los hechos materia del proceso atentando con ello, con la economía procesal².

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 132

Dependencia:	Dirección General
Número del Proceso:	1704-01-2014-069
Número y fecha del fallo:	00024 del diez (10) de octubre de dos mil catorce (2014)
Asunto:	Auto que resuelve recurso de apelación por negación de pruebas
Criterio de Selección:	Fallo de segunda instancia confirmados.

¹ Artículo 132 de la ley 734 de 2002.
² Sentencia C-401- de 2013.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del Auto que rechazó unas pruebas, proferido en primera instancia dentro del expediente disciplinario ITRC No. 1704-01-2014-069

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho de segunda instancia a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de confianza del procesado (XXX), contra la decisión negativa al decreto de unas pruebas solicitadas por la defensa en etapa de descargos, mediante providencia proferida por el subdirector técnico de investigaciones disciplinarias de la UAE Agencia ITRC, el pasado nueve (9) de octubre del año en curso en audiencia de juicio verbal dentro del expediente disciplinario 1704-01-2014-069.

COMPETENCIA

La suscrita Directora General de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, es competente para resolver la presente impugnación, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 4173 de 2011, aclarado por el Decreto 4452 de 2011, en atención a las previsiones contenidas en los numerales 12 y 13 del artículo 3° del Decreto 0985 del 14 de mayo de 2012 y al contenido de los artículos 115 y ss. de la Ley 734 de 2002.

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN IMPUGNADA

1.- Al presente juicio verbal disciplinario fue llamado a responder el funcionario (XXX), por la presunta incursión en la falta gravísima, prevista en el numeral 17 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, consistente en actuar a pesar de la existencia de causales de inhabilidad, generadas contra el aquí enjuiciado en la condena penal proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá D.C., el día 24 de mayo de 2010, por los punibles de concierto para delinquir, falsedad en documento público y cohecho.

2.- En la mentada audiencia de juicio verbal, el despacho a-quo negó parcialmente el decreto y práctica de algunas de las pruebas solicitadas por el apoderado del investigado (XXX), a saber:

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del Auto que rechazó unas pruebas, proferido en primera instancia dentro del expediente disciplinario ITRC No. 1704-01-2014-069

2.1.- Que se escuche en declaración jurada al señor (XXX), quien fue el encargado de reintegrar al procesado (XXX), es decir, fue el servidor público que firmó dicho acto administrativo, de tal forma que su deposición resulta pertinente.

2.2.- Oficiar a la jefatura de registro y control de correspondencia de la Procuraduría general de la Nación para que certifique las razones por las cuales esa entidad no registró para el día 17 de diciembre de 2011 el antecedente penal relacionado con el ciudadano (XXX), en cuya fecha alcanzó ejecutoria la sentencia condenatoria impuesta a (XXX), la cual fue proferida por la sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

3.- Fundamentó el despacho a-quo la negativa al decreto y práctica de la prueba relacionada con la declaración de (XXX), en cuanto a que *"La prueba es inconducente toda vez que para comprender la motivación de un acto administrativo se debe recurrir al estudio de su argumentativo, mas no, a la testimonial del funcionario público que extendió el acto. Toda vez que todas las apreciaciones personales, subjetivas o aún de criterio que no reposen en la estructura del acto administrativo, simplemente son inexistentes"* Sic.

4.- En cuanto a la solicitud de oficiar a la Procuraduría para que certifique el por qué no registró el día 17 de diciembre de 2011 el antecedente penal del enjuiciado, indico el despacho de primer grado *"el trámite de inscripción o anotación del precedente en la Procuraduría, corresponde con un trámite posterior y accesorio que no invalida la ejecutoria de la condena impuesta por la jurisdicción ordinaria o la vulneración de derecho alguno al aquí investigado"* Sic.

5.- Notificada en estrados la anterior decisión, la defensa del procesado interpuso recurso de apelación en los siguientes términos.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

En sentir de la defensa la declaración del señor (XXX) resulta necesaria por cuanto dentro del derecho disciplinario está prohibida la responsabilidad objetiva y *"sólo con la exposición que deba a hacer el señor (XXX) el proceso podrá conocer en detalle porque razones o quien indujo a dicho funcionario a disponer el reintegro de (XXX), Solamente en dicho acto administrativo, se exponen escuetamente razones de orden jurídico, pero no se precisa con mayor profundidad conceptual a qué se debió la decisión de reintegrar al señor (XXX) a pesar de que existía una sentencia condenatoria, un antecedente o un impedimento legal"* Sic.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del Auto que rechazó unas pruebas, proferido en primera instancia dentro del expediente disciplinario ITRC No. 1704-01-2014-069

Respecto de la prueba documental relacionada con la Procuraduría, indico que en versión libre su prohijado manifestó que cuando se produjo el fallo condenatorio penal había cambiado de abogado y que como este se encontraba en Bogotá no tuvo conocimiento en detalle de la decisión, agregando que como no es abogado, no tiene manejo sobre la ejecutoria de los fallos, concluyendo que *"Con esta constancia probatoria es claro que el disciplinado en aquella oportunidad no tenía conocimiento sobre la decisión que la justicia penal había tomado en su contra. De manera que la prueba documental solicitada se hace necesaria para poder conocer con certeza si mi asistido (XXX) es responsable disciplinariamente de la falta que se le está enrostrando, o por el contrario, su actuar estuvo inmerso en una causal de exclusión de responsabilidad" Sic.*

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Sea lo primero precisar cuál es la finalidad o el objeto del recurso de apelación, consagrado en el ordenamiento procesal disciplinario, con base en el artículo 115 de la Ley 734 de 2002, este despacho ad quem, tiene la función de examinar si el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, se encuentra previsto dentro de la taxatividad del ordenamiento procesal disciplinario del artículo 115 y si este a su vez goza de subvención prosperidad. Cualquier decisión adicional, escapa de la órbita y competencia legal que se confiere a este fallador de segundo grado³.

Como todos los recursos claramente descritos en la normatividad adjetiva disciplinaria, el recurso de apelación tiene un trámite y unos requisitos de procedibilidad, a saber:

- Que se interponga en términos (temporalidad y oportunidad del recurso), de conformidad con el artículo 111 del CDU.
- Que la decisión contra la cual se interpuso el recurso de apelación, sea efectivamente apelable, según las voces del artículo 115 del CDU, esto es contra la decisión que niega la práctica de pruebas solicitadas en los descargos, contra la decisión de archivo y el fallo de primera instancia.
- Que el recurso se haya interpuesto y sustentado en legal forma, acorde a las previsiones de la norma en cita.

³ Ley 734 de 2002 Artículo 171 parágrafo. El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del Auto que rechazó unas pruebas, proferido en primera instancia dentro del expediente disciplinario ITRC No. 1704-01-2014-069

En el sub examine, palmario es que la decisión que resolvió no acceder a la práctica de las pruebas impetradas por el recurrente, en efecto es apelable, pues en concordancia con lo señalado sobre el particular, dicha posibilidad en materia disciplinaria, está limitada entre otras, para los autos que niegan la práctica de pruebas solicitadas en la etapa de descargos, tal como en efecto ocurre en el sub examine.

Entonces de lo que se trata es de establecer sobre la pertinencia conducencia y utilidad de las pruebas que fueren negadas en la decisión atacada de primera instancia. Para decidir sobre la admisibilidad de las pruebas solicitadas por la defensa en los descargos resulta imperioso no apartarse del objeto de la prueba o "thema probandi" del proceso.

Doctrinariamente se define como objeto de la prueba, todo hecho que precisa demostración en el expediente, por constituir presupuesto de la decisión. Entonces la prueba debe estar enfocada o encaminada a todos aquellos aspectos de discusión que puedan servir de base para la definición de la situación jurídica del procesado. Con base en lo anterior, el artículo 132 de la Ley 734 de 2002 establece los requisitos básicos para la admisión de las pruebas, relacionados con su conducencia, pertinencia y utilidad.

La conducencia de la prueba tiene que ver con la capacidad de esta para demostrar un determinado acontecimiento; la pertinencia como la coherencia entre la situación investigada y la prueba a realizar, mientras la utilidad refiere a la trascendencia o riqueza probatoria que aporta la probanza a la investigación. Deben así inadmitirse las pruebas que resulten inconducentes, igualmente, las ilegales o ineficaces, las que versen sobre hechos impertinentes y las manifiestamente superfluas⁴.

Sobre este tópico la Jurisprudencia Constitucional ha precisado que el principio de pertinencia y conducencia e idoneidad de la prueba, constituyen una limitante a la libertad de la presentación de la prueba y están relacionados con los denominados requisitos intrínsecos del acto probatorio, pues de no ser así, al proceso concurrirían toda suerte de pruebas que al final no sería mucho lo que finalmente aporten al esclarecimiento de los hechos materia del proceso atentando con ello, con la economía procesal⁵.

⁴ Artículo 132 de la ley 734 de 2002.

⁵ Sentencia C-401- de 2013.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del Auto que rechazó unas pruebas, proferido en primera instancia dentro del expediente disciplinario ITRC No. 1704-01-2014-069

Al respecto, la Corte Constitucional reconoce un amplio margen de autonomía del funcionario instructor, para decidir sobre el decreto de las pruebas que estime pertinentes, conducentes y relevantes para determinar los hechos que son objeto de juzgamiento. En tal sentido afirma que el juez está revestido de competencia para definir si esas pruebas solicitadas son pertinentes, conducentes y procedentes, y si en realidad, considerados, evaluados y ponderados los elementos de juicio con los que dispone, ellos contribuyen al esclarecimiento de los hechos y a la definición acerca de la responsabilidad disciplinaria del procesado. Por ello, es posible que niegue alguna o algunas de tales pruebas, si estima fundadamente que los requisitos legales no se cumplen, o que en el proceso respectivo no tienen lugar, evitando siempre dilaciones injustificadas del proceso⁶.

Respecto a la presunta violación del derecho de defensa que pueda alegarse en un proceso disciplinario porque el fallo o decisión de primera instancia, no tuvo en cuenta las pruebas solicitadas por la defensa, la Corte considera que el juez puede obtener la verdad procesal con las herramientas que tuvo a su alcance dentro del proceso en primera instancia, esto es: i) la versión de los hechos del disciplinado; ii) la práctica de pruebas que considere conducentes y pertinentes; y iii) los alegatos de conclusión del investigado⁷.

Corolario con lo anterior, la negativa debidamente motivada de las pruebas que considere el despacho a-quo como inconducentes impertinentes o ineficaces, en nada cercenan el derecho a la defensa ni al debido proceso del sujeto procesal.

Para el caso concreto encuentra este sensor de instancia que el auto que rechazó o negó la práctica de la prueba referente a *"que se escuche en declaración jurada a (XXX), por haber sido el encargado de reintegrar al procesado, es decir, fue el funcionario que firmó dicho acto administrativo"*; se encuentra en efecto bien denegado y ajustado a la legalidad procesal de los presupuestos intrínsecos como extrínsecos del acto probatorio arriba deprecados, en cuanto a que se recuerda que lo que tiene que ver con la inconducencia de las pruebas hace correlación con su falta de aptitud legal para comprobar o demostrar los hechos debatidos. Así el medio idóneo para demostrar las consideraciones de un acto administrativo y sus efectos jurídicos, es el correspondiente acto administrativo, por cuanto como lo establece la ley, la doctrina y la jurisprudencia, uno de los atributos propios del acto mismo, entendido como la emisión de la voluntad de un organismo, autoridad o entidad pública, con el propósito de que produzca efectos jurídicos, es la denominada "presunción de

⁶ Ibídem.

⁷ Sentencia C-401-2013.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del Auto que rechazó unas pruebas, proferido en primera instancia dentro del expediente disciplinario ITRC No. 1704-01-2014-069

legalidad" que también recibe los nombres de "presunción de validez", "presunción de justicia", y "presunción de legitimidad"⁸.

Se trata entonces de una prerrogativa de orden legal de que gozan los pronunciamientos administrativos, que significa que, al desarrollarse y al proyectarse la actividad de la Administración en estos, responden a todas las reglas y efectos jurídicos sin excluir por supuesto el probatorio, por cuanto se presume en derecho, que se han respetado todas las normas que lo enmarcan. Así legalidad es sinónimo de perfección, de regularidad; se inspira en motivos de conveniencia pública, en razones de orden formal y material en pro de la ejecutoriedad y de la estabilidad de esa manifestación de voluntad de la Administración.

En tal sentido le asiste razón al despacho de primer grado en cuanto a que las elucubraciones de orden personal o la perspectiva subjetiva que pueda tener el funcionario o autoridad que expidió el acto, poco importan a la actuación jurídica o administrativa en donde esta haya surtido efectos, por cuanto como arriba se expuso con suficiencia no es la persona ni su criterio o perspectiva subjetiva la que profiere el acto, ni la que le comporta sus efectos jurídicos, sino la calidad de autoridad administrativa que depone con suficiencia sus argumentos en el libelo o parte considerativa del respectivo acto, con base en las pruebas legal y oportunamente allegadas al mismo, bajo estrictos criterio de reserva legal, como con plena subvención y advenimiento de las normas aplicables al caso particular, de donde se desprende no solo su presunción de legalidad y validez, sino sus efectos jurídicos, los cuales solo podrán ser rectificados o desestimados por la respectiva autoridad jurisdiccional administrativa y no por el operador disciplinario ni por los sujetos procesales, los cuales para todos sus efectos solo se supeditan a la parte resolutive de la decisión, entendida estas bajo las consideraciones o motivaciones del mentado acto administrativo que resulten vinculantes a la parte resolutive del acto.

En tal sentido no prospera el alegato sobre la pertinencia del llamamiento a declarar al funcionario que profirió o autorizó el respectivo acto.

En cuanto a la solicitud probatoria referente a que se oficie a la Procuraduría para que certifique el por qué no registró el día 17 de diciembre de 2011 el antecedente penal del enjuiciado, se insiste

⁸ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA CONSEJERO PONENTE: Álvaro lecompte luna Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994). Radicación número: 006264.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del Auto que rechazó unas pruebas, proferido en primera instancia dentro del expediente disciplinario ITRC No. 1704-01-2014-069

por esta instancia que en lo concerniente a la impertinencia de la prueba ella se refiere a la falta de concordancia entre los hechos que se debaten y los que se pretenden demostrar con las pruebas solicitadas.

En tal sentido y como lo expresara en su exposición de motivos a la negativa al decreto y practica de tal prueba el despacho a-quo, el trámite de inscripción o anotación del antecedente en la Procuraduría, corresponde a un trámite posterior, accesorio e independiente de la actuación penal o administrativa surtida en contra del enjuiciado⁹, que no invalida o suspende ni la ejecutoria de la condena ni su efectividad impuesta por la jurisdicción ordinaria, ni a sus efectos jurídicos, y que propende más por el control del hábeas de acceso a la función pública en todas sus modalidades, por lo que en estrictez no resulta axial a los elementos facticos constitutivos del thema probandi en la presente causa y que son materia de discusión y debate en juicio, resultando estos en la carta de navegación probatoria de la presente actuación disciplinaria, en consecuencia no cercena derecho alguno al aquí investigado su rechazo.

Por lo anterior no prospera el alegato sobre la pertinencia y conducencia de la solicitud del documento referido, por no encontrar asidero factico relevante y concordante con la presente actuación disciplinaria.

Recuérdese que el instructor de primer grado goza de una amplia autonomía e independencia en la producción, recaudo y valoración de las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso y como director del proceso debe velar por la constante evaluación y control legal y constitucional de las pruebas que vayan a obrar en el plenario bajo su orientación, sin que se vayan a ver cercenados derechos fundamentales ni de los sujetos procesales ni de terceros con la práctica probatoria del proceso¹⁰. Por la anterior razón considera este despacho que la anterior decisión se ajustó a los lineamientos procedimentales de los artículo 128 y 132 de la Ley 734 de 2002, el cual establece que serán rechazadas las pruebas inconducentes, impertinentes y superfluas y no se

⁹ Artículo 2º Ley 734 de 2002: La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta.

¹⁰ “...Sobre este punto, vale la pena precisar que en el ámbito de los procesos disciplinarios no existe una tarifa probatoria legal; de hecho el propio Código Disciplinario Único consagra, en su artículo 131, el principio de libertad probatoria, al establecer que “la falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos”. De manera tal que no es aceptable exigir que se haya recaudado un tipo determinado de pruebas –por ejemplo un testimonio o un documento- para efectos de sustentar un fallo disciplinario, que puede estar basado, por decisión expresa del Legislador, en cualquiera de los medios probatorios admitidos por el sistema legal colombiano –e incluso en otros medios probatorios, como se deduce del artículo 130 *ibídem* -. Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil trece (2013). Radicación número: 11001032500020110012100 (041311).

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del Auto que rechazó unas pruebas, proferido en primera instancia dentro del expediente disciplinario ITRC No. 1704-01-2014-069

atenderán las practicadas ilegalmente, debiendo declararse así en la parte resolutive de esta decisión.

Con estas consideraciones, resulta imperioso para esta instancia afirmar que los motivos de impugnación del recurrente, no encuentran subvención de prosperidad y por tanto habrán de negarse las prueba consideradas en esta instancia, por las razones arriba ponderadas.

En tal virtud, la Directora General de la UAE Agencia del Inspector general de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la decisión calendada el nueve (9) de octubre del año en curso, proferido por el subdirector técnico de investigaciones disciplinarias de la UAE Agencia ITRC, mediante la cual negó la práctica de unas pruebas, con fundamento en las razones ut supra.

SEGUNDO. NOTIFICAR el contenido de esta decisión a los sujetos procesales, de conformidad con las previsiones legales contenidas en los artículos 103 y 106 de la Ley 734 de 2002, Para el efecto, por la secretaría técnica de esta UAE Agencia ITRC, devuélvanse las diligencias a la subdirección técnica de investigaciones disciplinarias de esta unidad, para que proceda a dar cumplimiento a la decisión de segundo grado.

TERCERO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

CUARTO. La presente decisión queda en firme el día de su suscripción, pero sus efectos jurídicos se surten a partir de su notificación, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 734 de 2002.

CÓPIESE NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del Auto que rechazó unas pruebas, proferido en primera instancia dentro del expediente disciplinario ITRC No. 1704-01-2014-069

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE

Directora General

Proyectó: Dr. Julian Andres Garcia Novoa
Aprobó: Dr. (a) Carmen Maritza González M.